

次のⅠ及びⅡの【見解】は、裁判所が公判廷において鑑定を命じた鑑定人によって鑑定書が作成された場合に、その鑑定書を公判廷においてどのような手続により取り調べるのかという問題に関するものである。この見解について述べた後記のＡからカまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記１から６までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 裁判所は、当事者の取調べ請求を待たず、鑑定書を公判廷において取り調べる必要がある。
- Ⅱ. 裁判所は、鑑定書を公判廷において取り調べるためには、原則として、当事者からその取調べ請求を受ける必要がある。

【記 述】

- ア. Ⅱ説は、鑑定書が公判準備における鑑定人の尋問の結果を記載した書面と実質上何ら変わらないとして、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続と同様にすべきと考えるものである。
- イ. Ⅱ説は、鑑定書の取調べを当事者の意思にかからしめることが証拠調べにおける当事者主義からみて当然のことであるとするものである。
- ウ. Ⅰ説は、裁判所が鑑定書による報告を命じたことにつき、当然その鑑定書の取調べを予定しているものであるとするものである。
- エ. Ⅱ説によれば、鑑定請求をした弁護人が、鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べた場合、その請求は、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解することになる。
- オ. Ⅰ説によれば、弁護人及び検察官のいずれもが、鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べた場合、裁判所は、職権で、刑事訴訟法第321条第4項の手続を履践すべく、鑑定人を証人として尋問する旨の決定をしなければならない。
- カ. Ⅱ説によれば、鑑定請求をした弁護人が、鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べ、検察官が、鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べた場合、検察官は、裁判所に鑑定書を取り調べてもらうためには、刑事訴訟法第321条第4項の立証手続として鑑定人を証人として尋問する旨の請求をする必要がある。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ カ
6. オ カ

No.332

鑑定書の取調べ手続

正答率

H23-36

正解

2

40%

本問において、見解Ⅰと見解Ⅱとは、鑑定書の取調べが、職権により行われなければならないか、当事者の証拠調べ請求により行われなければならないかにつき、見解が分かれている。

見解Ⅰ

見解Ⅰは、鑑定書の取調べは鑑定決定の施行に過ぎず、いわば公判準備に行った鑑定人尋問の結果を記載した調書の取調べと実質的に同一であるから、303条の類推適用があり、改めて取調べの請求も決定も要せず、当然に取り調べなければならないとする。ただ、鑑定書の証拠能力については、320条1項の適用があり、326条の当事者の同意又は321条4項により証拠能力を取得することを要する。321条4項の適用は、鑑定書を作成した鑑定人を証人として尋問することが前提となり、その証人尋問について別個の証拠調べ手続がとられることになる（請求によるべきか、職権で行うべきかは争いがある）。

見解Ⅱ

見解Ⅱは、鑑定請求には鑑定書の取調べ請求を含まず、また鑑定決定の施行は鑑定人尋問であるから、鑑定書を取り調べるには改めてその証拠調べの請求が必要であるとしている。

なお、この点につき職権証拠調べも可能と解するため、問題文において、原則としてとの留保が付けられている。この考え方は、鑑定の経過や結果の報告は鑑定を命じるという形で出された質問に対する答えであり、320条1項の法意にも照らし、法廷において口頭で述べるのが本則であるという基本理念に基づく。すなわち、当初開始した鑑定人尋問は、鑑定人がその判断を述べるにあたり、鑑定処分などの事実行為を要するために一時中断したにすぎず、その判断が述べられるような状態に達したときは中断した鑑定人尋問を再開して、口頭で報告させるというのが本来法の予定した鑑定という証拠調べ手続であると考えるのである。そのため、鑑定書の取調べは、中断した鑑定人尋問と別個の証拠調べ手続である以上、これを行うにあたっては、当事者による請求が必要となる。

ア 誤っている

303条によると、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面に関しては、裁判所に職権証拠調べ義務が生じ、裁判所は当事者の取調べ請求（298条1項）を待たず、当該書面を公判廷において取り調べる必要があるとされている。Ⅱ説は、鑑定書を公判廷において取り調べるためには、原則として、当事者からその取調べ請求を受ける必要があるとしており、鑑定書について、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続と同様に、裁判所に職権証拠調べ義務が生じるとは解していない。したがって、本記述は、Ⅱ説は、公判準備における証人尋問等の結果を記載した書面の取調べ手続と同様にすべきでないとするべきところ、同様にすべきとしている点で、誤っている。

なお、Ⅰ説は、鑑定書の取調べは鑑定決定の施行に過ぎず、いわば公判準備に行った鑑定人尋問の結果を記載した調書の取調べと実質的に同一であるから、303条の類推適用があるとしており、本記述はⅠ説の根拠となる。

イ 正しい

Ⅱ説は、鑑定書を公判廷において取り調べるためには、原則として、当事者からその取調べ請求を受ける必要があるとしており、裁判所に、職権証拠調べ義務を認めていない。これは、証拠調べにおいて当事者主義が採用されており、職権証拠調べは補完的なものである以上、鑑定書の取調べを当事者の意思にかからしめることが、証拠調べの原則たる当事者主義からみて当然のことであると考えているためである。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

本記述は、Ⅰ説の根拠として、裁判所が鑑定書による報告を命じたことにつき（規則 129 条 1 項、129 条 3 項）、当然その鑑定書の取調を予定しているものであるとしている。裁判所が鑑定書による報告を命じた以上、鑑定書の取調を行わなければ、鑑定を命じた意味がなくなる。そのため、裁判所は当然その鑑定書の取調を予定しているものであり、当事者の鑑定書の取調べ請求を待たず、鑑定書を公判廷において取り調べる必要があると解することになり、これはⅠ説の根拠になる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

本記述は、Ⅱ説によると、鑑定請求をした弁護人が、鑑定書の取調べの請求をする旨の意見を述べた場合、その請求は、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見（326 条 1 項）と解することになるとしている。Ⅱ説によると、鑑定書を公判廷において取り調べるためには、当事者からその取調べの請求を受ける必要があるとしているところ、当事者が鑑定書の取調べ請求をして、初めて、伝聞証拠としての証拠能力の問題になる。そのため、鑑定書の取調べの請求をする旨の意見は、あくまで、証拠調べ請求の意義しか有さず、この請求を、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解することはできない。したがって、本記述は、鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べた場合、その請求は、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解することはできないとすべきところ、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解することになるとしている点で、誤っている。

オ 誤っている ★

Ⅰ説によれば、当事者による鑑定書の取調べ請求がなくとも、裁判所は、鑑定書を公判廷において取り調べる必要がある。もっとも、鑑定書は伝聞証拠であり、当然には証拠能力がないから、326 条の同意があるか又は 321 条 4 項による手続を経た後でなければ、これを証拠とすることはできず、この証人尋問について別個の証拠調べ手続がとられることになる。本記述において、弁護人及び検察官のいずれもが、鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べているため、かかる取調べ請求を、鑑定書を取り調べることに同意する旨の意見と解するⅠ説においても、326 条の同意はないといえる。そこで、次に 321 条 4 項を検討すると、鑑定書を作成した鑑定人に対する証人尋問については、請求によるべきか、職権で行うべきかについては争いがある。請求によるべきとの説によれば、裁判所が職権決定を行う必要はない。したがって、本記述は、裁判所は、職権で、321 条 4 項の手続を履践すべく、鑑定人を証人として尋問する旨の決定をしなければならないとしている点で、誤っている。

カ 正しい ★

Ⅱ説によると、鑑定書の取調べには、当事者からの取調べ請求が必要となる。本記述においては、検察官が鑑定書の取調べ請求をする旨の意見を述べているため、裁判所は、証拠決定をして、これを取り調べることができる。もっとも、鑑定書は伝聞証拠にあたるため、326 条の同意又は 321 条 4 項の手続の履践が必要となる。本記述では、弁護人が鑑定請求をしたが、鑑定書の取調べ請求をしない旨の意見を述べており、弁護人による 326 条の同意は期待できない。そのため、検察官は、裁判所に鑑定書を取り調べてもらうためには、321 条 4 項の立証手続として鑑定人を証人として尋問する旨の請求をする必要があり、この証人尋問手続を経たあとで、裁判所は鑑定書につき、証拠決定をして、これを取り調べることになる。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はア、エ、オであり、したがって、正解は肢 2 となる。

